

DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS

DIREITOS e DEVERES INDIVIDUAIS e COLETIVOS (ART. 5º da CF)

Atualmente, o art. 5º da Constituição Federal, de 1988, tem 79 incisos e quatro parágrafos. Os incisos 78 e 79, bem como dois dos quatro parágrafos, entraram no texto constitucional por emenda.

Cláusula pétrea pode ser modificada? Sim, desde que seja para ampliar a proteção. As cláusulas pétreas não podem ser modificadas para abolir direitos.

Embora o art. 5º seja muito extenso, ele se apresenta em rol exemplificativo, ou seja, comporta ampliação, de modo que outros direitos fundamentais podem ser incorporados ao longo do tempo, mesmo por meio de tratados internacionais. Exemplo: em janeiro de 2022, o direito brasileiro internalizou um tratado internacional de direitos humanos com status constitucional, ligado à ideia de cotas raciais. Hoje, as cotas raciais são consideradas normas constitucionais.

Agora, será feita a análise do art. 5º, sem dúvidas o mais importante ponto do texto constitucional.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

I – homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição;

Igualdade formal x material x compensatória

O inciso I permite o tratamento diferente entre homens e mulheres quando a diferença se justificar. Exemplo: a aposentadoria voluntária de homens e mulheres normalmente têm idades diferentes (65 e 62 anos, respectivamente). A licença gestante é de 120 dias no texto constitucional, ao passo que a licença paternidade é muito menor.

Quando o *caput* do art. 5º dispõe que todos são iguais perante a lei, é preciso retornar à Antiguidade para falar de Aristóteles, Sócrates e Platão, que criaram teses que até hoje são seguidas e respeitadas.



5m

ANOTAÇÕES

Rui Barbosa defendia que a igualdade não pode ser apenas formal, embora o tratamento igual a todos seja um bom ponto de partida. Mesmo quando se promove um tratamento igual a todos, é possível incorrer em desigualdade. A seguinte ilustração ajuda a entender isso melhor: imagine que três crianças (uma pequena, uma de estatura média e uma alta) foram colocadas em cima de três caixas de madeira iguais atrás de um painel de publicidade em um estádio de futebol. A criança pequena continua sem ver o gramado, a de estatura média fica com a visão adequada e a criança alta fica com a visão mais privilegiada do gramado. Houve igualdade formal, pois cada criança recebeu uma caixa; contudo, não houve igualdade material, uma vez que a criança pequena precisava de pelo menos mais uma caixa.

A igualdade formal é dar tratamento igual aos iguais, ao passo que a igualdade material é dar tratamento igual aos iguais e desigual aos desiguais, igualando-os na medida de sua desigualdade. A ideia é igualar no direito o que a vida desequilibrou, permitindo discriminações positivas. Essa perspectiva permite a criação de ações afirmativas, como as cotas raciais e sociais (igualdade compensatória).

É de conhecimento geral que os negros foram escravizados. Assim, as cotas raciais surgem como uma medida compensatória, dentro da premissa da igualdade material. O ideal seria que as cotas não fossem necessárias, pois isso indicaria que a sociedade alcançou um ponto de equilíbrio.

Direito à vida, à liberdade e à propriedade

O direito à vida também é prestigiado pelo *caput* do art. 5º, e a vida é assim entendida desde a concepção. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), inclusive, delimitou a possibilidade de preservar alimentos para crianças que ainda não nasceram, os chamados alimentos gravídicos. O STF prestigia a pesquisa com embriões congelados e com células-tronco. Dentro dessa discussão, o ex-ministro do STF, Ayres Britto, fez a seguinte ilustração: pegou fogo em dois lugares da cidade, um laboratório de pesquisa genética, onde foram destruídos 20 mil embriões congelados, e um orfanato, onde morreram queimadas 40 crianças. Para onde o corpo de bombeiros deveria ir primeiro? Qual dos eventos será noticiado pela imprensa com mais vigor?

O ministro Ayres Britto associou a dignidade da pessoa humana ao princípio da felicidade para afirmar que, se as pesquisas com células-tronco forem utilizadas para garantir uma vida plena e feliz, elas deveriam ser permitidas no ordenamento jurídico brasileiro.



10m

ANOTAÇÕES

O direito à liberdade é prestigiado em vários pontos da Constituição. Por exemplo, a prisão cautelar, a prisão provisória, a prisão temporária e a prisão preventiva são exceções. Não por outro motivo, o STF oscila a sua jurisprudência para determinar se pode ou não haver prisão após julgamento em segunda instância. A regra é a prisão apenas após o trânsito em julgado.

Vários dispositivos importantes para as provas reverberam sobre a questão da propriedade. Exemplo: a desapropriação, a requisição temporária de bens de particulares.

Existe uma falha na redação do art. 5º no seguinte trecho: *garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País*. A Constituição traz menos do que deveria, pois mesmo estrangeiros não residentes têm direito à vida e à propriedade. A ideia a ser, de fato, levada em conta é a seguinte: *garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros que estejam no País*. Exemplo: um dos benefícios de assistência social, o Benefício de Prestação Continuada (BPC), também pode ser assegurado a estrangeiros residentes no país, de acordo com o STF. Outro exemplo: o Brasil não admite pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Contudo, em países como a Tailândia a posse de cocaína é punida com a pena de morte, e alguns brasileiros incorreram nesse crime.

A questão das cotas em universidades e o princípio meritocrático

Considere o seguinte exemplo: em uma disputa por vagas na UnB, a nota de corte dos que optaram pelas cotas era menor do que a nota de corte da ampla concorrência. Alguns candidatos da ampla concorrência tiraram uma nota abaixo da nota de corte geral, mas acima da nota de corte das cotas. É preciso lembrar que, enquanto a educação básica é obrigatória e gratuita, abrangendo a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, o acesso aos níveis mais elevados de ensino, de acordo com a Constituição, deve se dar de acordo com a capacidade de cada um, pois não há vagas para todos nas universidades públicas.

Isso recebe o nome de princípio meritocrático. Assim, chegou ao STF a seguinte discussão: na disputa por uma vaga na UnB, não entrou o cidadão que tinha melhor nota que o cotista, supostamente ferindo o princípio meritocrático. Por unanimidade, o STF julgou que as cotas em universidades são válidas, pois compatibilizam o princípio meritocrático com a igualdade material. O mesmo vale para os concursos públicos.



15m

ANOTAÇÕES

Em se tratando de cotas raciais, basta o critério da autodeclaração ou a banca pode pedir um exame a ser feito por uma banca multidisciplinar? A exigência de banca é legítima para verificar se o candidato tem as características fenotípicas que demonstrem se tratar de pessoa negra. Lembrando que, na tábua de cores do IBGE, existem cinco possibilidades: branco, amarelo (oriental), indígena, preto ou pardo. A definição de negro abrange os pretos e pardos. O grande desafio das cotas raciais é a grande miscigenação do povo brasileiro. Muitas vezes, injustiças são cometidas, como no caso em que dois irmãos gêmeos concorreram a uma vaga na UnB, mas apenas um deles foi admitido pelo critério de cota. A equipe multidisciplinar é importante justamente para evitar abusos por parte dos candidatos.

Uma lei federal de 2014 implementou cotas raciais no âmbito do Executivo Federal. Quando o STF analisou, entendeu que a lei não deveria ser aplicada apenas para o Poder Executivo Federal, mas para toda a esfera federal, reservando 20% das vagas. Contudo, a lei federal não poderia incidir sobre todas as esferas de governo. Estados, municípios e o Distrito Federal (DF) deveriam fazer leis próprias a esse respeito.

Benefícios da execução penal

Quando o cidadão recebe uma pena alta, ele começa a cumpri-la no regime fechado, depois passa para o semiaberto, aberto e o livramento condicional. Para ter acesso a alguns benefícios da execução penal, é preciso comprovar ter uma ocupação lícita. Contudo, ex-presidiários enfrentam grande dificuldade em conseguir um emprego com carteira assinada. A situação também é ruim para estrangeiros em situação irregular. Assim, o STF mudou seu entendimento e definiu que mesmo estrangeiros em situação irregular têm direito aos benefícios da execução penal.



20m

Cobrança de preço diferenciado nas mensalidades de alunos deficientes

Aqueles que têm filhos deficientes, muitas vezes, passam por situações de discriminação velada. Por exemplo, é difícil encontrar vagas para deficientes em escolas privadas.

O STF impede a cobrança de preço diferenciado nas mensalidades de alunos deficientes. Embora a escola, muitas vezes, precise contratar um monitor especialmente para esse aluno deficiente, o STF entendeu que a escola deve diluir o custo para todos.

ANOTAÇÕES

Cobrança de valor para leitos diferenciados pelo SUS

Existem hospitais privados e públicos. Alguns hospitais privados fazem convênio com o SUS. Assim, se não houver mais vagas no hospital público, o governo deve custear o atendimento em hospital privado conveniado, que receberá o dinheiro do poder público. O STF determinou que não pode haver cobrança por leitos diferenciados, quando o atendimento é feito pelo SUS.

Direito sucessório: cônjuges x companheiros

O STF não permite tratamento discriminatório para uniões estáveis ou casamento entre pessoas do mesmo sexo. Uniões heteroafetivas e homoafetivas são ambas protegidas pelo princípio da igualdade.

Obs.: o STF entende que é possível a alteração do nome e sexo em documentos, ainda que não tenha sido realizada cirurgia de redesignação sexual. Essa alteração pode ser feita no cartório ou por via judicial. Trata-se de um importante mecanismo de reconhecimento de dignidade.

Da mesma forma, o STF não permite tratamento discriminatório entre companheiros e cônjuges sobreviventes.

Antigamente, o Código Civil dava tratamento diferente para casados ou em união estável quando do falecimento de um dos companheiros, beneficiando muito mais os casados. Ademais, o art. 226 da Constituição dispõe que a lei favorece a conversão de união estável em casamento. Contudo, o art. 1.790 do Código Civil foi declarado inconstitucional, exatamente por permitir o tratamento diferente entre casamento e união estável. Assim, essa diferença de tratamento não existe mais.

TAF: 2ª chamada e a situação das gestantes

O STF entende que a justiça viola o princípio da isonomia quando oferece a 2ª chamada do Teste de Aptidão Física (TAF) para um candidato em detrimento de outro. Assim, surgiu a seguinte tese: a justiça não pode deferir 2ª chamada do TAF. O edital deve prever 2ª chamada para todos ou para ninguém.



25m

ANOTAÇÕES



Em relação à gestante, ela sempre terá direito à 2ª chamada, por conta da proteção à maternidade.

O STJ trouxe uma decisão semelhante: deve haver 2ª chamada no curso de formação para mulher que esteja amamentando, pela mesma razão da proteção à maternidade e à primeira infância.

Pensão por morte e regras diferentes para homens e mulheres

Algumas vezes, as diferenças de tratamento são escamoteadas pelo legislador. Exemplo: uma lei do Rio Grande do Sul dispunha que, em caso de pensão por morte, se a sobrevivente for uma mulher, presume-se dependência econômica e, portanto, existe o direito à pensão. Por outro lado, se o sobrevivente for homem, este precisa comprovar dependência econômica para receber pensão. Trata-se de uma lei preconceituosa, para dizer o mínimo. Quando o tema chegou ao STF, este declarou a lei inconstitucional, pois essa diferenciação não tinha justificativa.



EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

1. No tocante à temática dos Direitos e Garantias Fundamentais, assinale a alternativa correta.
 - a. O regime jurídico das liberdades públicas protege as pessoas naturais, brasileiras ou estrangeiras, residentes no Brasil, mas não as pessoas jurídicas
 - b. A Constituição Federal, segundo a doutrina, adotou o princípio da igualdade de direitos, prevendo uma igualdade de possibilidades virtuais.
 - c. Os direitos e garantias fundamentais enunciados na Constituição não se aplicam aos estrangeiros em trânsito pelo território nacional.
 - d. A conquista constitucional da liberdade religiosa trouxe a proibição do ensino religioso como disciplina em escolas públicas.
 - e. A Constituição impede a violação das comunicações telefônicas, ainda que haja ordem judicial autorizando.

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO

A igualdade é de antemão. No caso concreto, deve-se verificar se se trata de igualdade formal ou material.

A obrigatoriedade do ensino religioso foi proibida.

A regra é o sigilo, mas em casos concretos o afastamento do sigilo é possível.

GABARITO

1. b

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Aragonê Nunes Fernandes.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
